

一、诈骗罪的判定要点

司法实践中，诈骗罪与非法经营罪易产生混淆。从犯罪构成来看，两者主观上都有犯罪故意，但主体、客体、客观要件均有较大区别。本案中，代某等不具备证券投资咨询资质而推荐股票及虚构事实、隐瞒真相使被害人因受到欺骗而向其交费用，兼有非法经营行为和诈骗行为，且诈骗行为是目的行为，按照择一重处原则，应构成诈骗罪，而不是非法经营罪。下面，结合本案梳理构成诈骗罪的判定要点。

（一）主观上是否以非法占有为目的

是否以非法占有为目的认定诈骗罪成立与否的关键。刑事被告人有无非法占有目的，可通过被告人实施的客观行为来判断。本案中，代某及其聘用人员均没有专业知识，其根本没有能力保证客户买的股票能盈利，且代某供述，他们既没有投资专家提供投资股票建议，也没有内幕消息和内部操盘手操作，其虚构事实、隐瞒真相，是为了骗取客户信任，使被害人陷入错误认识而向其交付提成、服务费等，事实上股票的涨跌跟他的推荐没有任何关系。在这样的前提下，应认定代某等是以非法占有为目的。

（二）是否有欺骗行为

构成诈骗罪必须以使用欺骗方法骗取数额较大公私财物为前提。形式上欺骗行为包括虚构事实和隐瞒真相，实质上使对方陷入错误认识而处分财产。本案中，代某在不具备证券投资咨询资质及股票知识的情况下，招募亦无股票相关知识的其他被告人，虚构荐股资质、有内幕消息、有实力拉升股价、稳赚不亏等事实，隐瞒公司员工不懂股票的真相，冒充知名证券公司工作人员，骗取被害人信任，使被害人陷入错误认识而向被告人代某等人支付提成、服务费等费用，符合欺骗行为的形式要件和实质要件，应认定有欺骗行为。

（三）行为人欺骗行为与被害人遭受财产损失有因果关系

被害人基于对被告人的信任而交付相应费用使其财产受损，应认定两者之间存在因果关系。本案中，虽然股票的涨跌跟代某等的推荐没有任何关系，但他们以公司有专业的股票分析师和内部消息，有实力进行建仓拉升股价、盈利

率高等为诱饵，骗取被害人信任，进而向被害人收取服务费或与被害人就其股票获利金额进行分成。因此，被害人的财产损失与代某等的欺骗行为有因果关系。

二、非法获取公民个人信息并利用这些信息实施其他犯罪的罪数认定

司法实践中，为了诈骗他人钱财而非法获取他人信息案件频发。对行为人非法获取公民个人信息又利用这些信息实施其他犯罪的罪数认定，应看行为人非法获取公民个人信息的行为能否单独成立犯罪，如不单独成立犯罪，不构成牵连犯，则作为量刑加重情节考虑；如单独成立犯罪，则构成牵连犯，以择一重处为原则，数罪并罚为例外。

本案中，代某通过购买等方式获取公民个人信息，属于《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”，构成侵犯公民个人信息罪。其又利用这些个人信息实施诈骗行为，同时构成诈骗罪及侵犯公民个人信息罪。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。因此，应对代某以诈骗罪和非法获取公民信息罪进行数罪并罚。

编写人：河北省石家庄市桥西区人民法院 王红阁 郑丽君 贾茵

由于客观条件无法逐一收集被害人陈述的涉众型诈骗犯罪，
可以根据在案证据综合认定犯罪数额

——于某甲等诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02刑终462号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

被告人于某甲伙同他人先后成立北京某甲公司、北京某乙公司，并担任北京某甲公司股东、北京某乙公司股东法定代表人。2020年9月至2022年3月，被告人于某甲伙同先后担任业务员及后勤文员的于某乙，初审鉴定师杨某某，先后担任业务员、业务组长的鲁某某及业务员韩某某等人，以北京某甲公司、北京某乙公司名义，通过电话、网络等方式联系被害人，向被害人夸大藏品价值，虚构买家等事实，诱使被害人对藏品价值产生错误认知，以为可以高价出售藏品，以帮助客户出售收藏品需要鉴定等理由骗取被害人王某某等人鉴定费人民币400余万元。本案报案被害人涉及金额27万余元，未报案被害人涉及金额411万余元。

【案件焦点】

本案大部分被害人没有报案，由于客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述，未报案的被害人被骗金额能否认定为犯罪数额。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：因本案系通过电信联络不特定的被害人，涉案被害人众多，区域范围广，且单笔涉案金额不大，故存在未报案人员的情况，确因客观原因无法查找全部被害人，但经具有合法资质的鉴定机构经法定程序，根据账本明细、工资表、协议、收据、交易流水等相互印证的客观证据审计鉴定自2020年9月至2022年3月诈骗金额共计400余万元以及在案各被告人相关涉案金额(业绩)和薪酬，该鉴定意见程序合法，内容真实、客观，足以准确审计出报案和未报案人员的被诈骗数额及各被告人参与或应当负责的诈骗数额，故判决：

一、被告人于某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币13万元；

二、被告人于某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3万元；

三、被告人鲁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3万元；

四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；

五、被告人严某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2万元；

六、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1万元；

七、被告人文某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元；

八、被告人耿某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元；

九、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元；

十、责令被告人于某甲、鲁某某、于某乙、杨某某、严某某、韩某某、耿

某、杜某某、文某退赔违法所得，发还相应被害人。扣押在北京市大兴区人民检察院及本院的被告人鲁某某、于某乙、杨某某、严某某、韩某某、耿某、杜某某退赔的部分或全部违法所得冲抵上述各自退赔款及罚金，不足部分，继续追缴。冻结的于某甲平安银行账户、中信银行账户、招商银行账户及北京某甲公司招商银行账户对公账户、北京某乙公司招商银行账户对公账户，冲抵上述被告人于某甲的退赔款；

十一、扣押物品，依法予以处理。

一审宣判后，于某甲、杨某某提出上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：原判采纳具有合法资质的鉴定机构经法定程序，根据在案账本明细、工资表、收据、交易流水等相互印证的客观证据审计出的涉案数额，认定本案犯罪数额及各被告人参与或应当负责的诈骗数额，并无不妥。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，责令退赔项及对涉案物品的处理亦无不当，审判程序合法，应予维持。故裁定：

一、准许上诉人杨某某撤回上诉；

二、驳回上诉人于某甲的上诉，维持原判。

【法官后语】

本案确系由于客观原因的限制，无法逐一收集被害人陈述的涉众型诈骗犯罪，诈骗数额的认定存在证明困境，一方面，本案证明对象数量庞大。在案已对79名被害人收集笔录认定诈骗数额27万余元，但还有411万余元诈骗数额对应的被害人没有报案，人数远多于已报案的被害人，难以具备向所有被害人取证的可能性。另一方面，本案按照传统印证证明模式，对犯罪数额的核实存在客观不能，在被害人陈述这一直接言词证据不能取得的情况下，证据链条之间的相互印证会存在相对不能，因此需要多种证据拼凑整合，从而综合认定犯罪数额。

从本案诈骗模式上看，于某甲等人以公司名义，向客户夸大藏品价值，虚构买家等事实，诱使被害人对藏品价值产生错误认知，使其以为可以高价出售藏品，以帮助客户出售收藏品需要鉴定等理由骗取被害人鉴定费，其行为不同

于正常的藏品鉴定收取费用，符合诈骗罪的构成要件。具体到本案犯罪数额的认定，本案系通过通讯工具联系不特定人员实施的诈骗，涉案被害人众多，区域范围广，且单笔涉案金额不大，存在较多被害人未报案的情况。在本案基本犯罪事实已经有相应的客观性证据证明的情况下，由于客观条件的限制，对被害人无法逐一收集相关的言词证据，笔者认为，能够参照适用“综合认定”的证明方法。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。所称电信网络诈骗是指“利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动”“侵犯公民个人信息，扰乱无线电通讯管理秩序”的犯罪。又有《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第二十一条的规定，对于涉案人数特别众多的信息网络犯罪案件，确因客观条件限制无法收集证据逐一证明、逐人核实涉案账户的资金来源，但根据银行账户、非银行支付账户等交易记录和其他证据材料，足以认定有关账户主要用于接收、流转涉案资金的，可以按照该账户接收的资金数额认定犯罪数额，但犯罪嫌疑人、被告人能够作出合理说明的除外。案外人提出异议的，应当依法审查。本意见所称信息网络犯罪案件包括：(1)危害计算机信息系统安全犯罪案件；(2)拒不履行信息网络安全管理义务、非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动的犯罪案件；(3)主要行为通过信息网络实施的诈骗、赌博、侵犯公民个人信息等其他犯罪案件。具体到本案中，上诉人及原审被告主要是通过购买数据后使用通信工具、电信等方式联系不特定人员实施的诈骗，还有少数被害人称是通过网上搜索联系相应人员，藏品大部分通过邮寄，也有线下鉴定的情况，故本案不属于严格意义上的电信诈骗或信息网络犯罪案件。但本案整体诈骗模式一致，且被害人交易均

通过涉案公司公户，全案证据支撑较好，所有被害人的身份情况、交易金额均在公司有明确登记，结合客观证据通过审计可以得出未报案人员及涉案金额、各被告人相关涉案金额和违法所得。并且，被害人是否报案本身不是认定行为构成诈骗罪的必要条件。因此，可参照上述规定，对于确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的涉众型诈骗，通过具有合法资质的鉴定机构经法定程序，综合在案账本明细、工资表、收据、交易流水等相互印证的客观证据审计出的涉案数额，可以作为认定犯罪数额的依据。

编写人：北京市第二中级人民法院 王钰楠

用赃款“直播打赏”网络主播的追缴规则

—— 李某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省吉安市中级人民法院(2023)赣08刑终121号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2021年3月，时任某高速扩建A1 标项目部副经理的被告人李某与被害人 刘某相识。2021年4月中旬至7月，被告人李某虚构项目部需要资金，以“借款”名义从被害人刘某处骗取17笔款项共计145万元。所得款项基本用于挥霍 至某公司网络平台打赏给主播。

2021年6月至7月，被告人李某虚构项目部需要资金周转，以“借款”的名义从多年认识的被害人金某处骗取11笔款项共计25万元。所得款项基本用

于挥霍至某公司网络平台打赏给主播。

2021年11月17日公安机关立案后，被告人李某分别于2022年1月、5月退还了2万元、5000元给被害人金某。

经调取某公司材料显示，2021年4月1日至9月30日，被告人李某在某公司个人账户1共计充值237.8788万元，总消费241.16212万元；个人账户2共计充值6.2003万元，总消费6.19372万元。

公安机关在侦查期间，于2023年1月10日冻结了某公司银行账户资金104.233329万元。

另查明：被告人李某打赏给网络主播的礼物金额共计239.5131万元。

【案件焦点】

用赃款进行直播打赏可否进行刑事追缴及追缴的对象。

【法院裁判要旨】

江西省吉安市吉安县人民法院经审理认为：被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。李某诈骗被害人财物打赏给某公司网络主播。李某的打赏与某公司主播提供的服务不是一种对价的交易行为。李某打赏至某公司网络平台上的款项，明显超过了合理对价，且该公司主播与李某有不正当的男女性行为，明显违背了公序良俗，主播不构成善意。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条的规定，行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，对方是无偿取得诈骗财物的，应当依法追缴，某公司从李某处获取的打赏资金依法应予追缴。

综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条之规定，判决如下：

一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；

二、追缴某公司违法所得167.5万元，发还给被害人刘某、金某。
一审宣判后，李某提出上诉。

江西省吉安市中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，故裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实践中，对于用赃款进行打赏可否进行刑事追缴及追缴的对象这一问题一直存在不同认识。厘清直播打赏行为的法律性质，对统一赃款打赏行为的追缴规则具有积极意义。

一、“直播打赏”属有偿消费活动

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条确立了已被处分的赃款赃物构成善意取得的可免于刑事追缴。直播打赏款能否进行刑事追缴，前提是需要对“直播打赏”行为进行法律定性。关于“直播打赏”行为的法律性质，理论界和实务界一直存在“赠与说”与“服务合同说”等分歧观点。

笔者认为，“直播打赏”不具备完全无偿的特征，不应认定为无偿赠与关系，也不属于附条件的赠与关系，而应属有偿消费活动。首先，主播为了获得优质直播的能力，必须付出时间、精力、智慧以吸引用户，主播提供的是一定的表演服务。《中华人民共和国著作权法》赋予了表演者通过信息网络传播表演获得报酬的权利。直播平台为了确保直播活动顺利进行，需要组织大量的人力、财力组建团队，孵化、包装主播，并进行商业引流和提供平台服务相应的技术支持，产生了一定的运营成本。用户观赏直播，与主播进行互动，可以实现情感的满足，获得精神上的愉悦。当用户在直播间打赏时，直播间会根据用户的打赏金额、频次等，为用户提供打赏榜靠前、主播额外关注等更为个性化的服务。正是这种差异化的服务、精神上的高度满足，才会激励用户支付更多的打赏。其次，直播经济属于新兴业态，尊重付费打赏的商业合理性实际也是

肯定消费形式的多元化。

二、网络主播与用户建立不当男女关系有违公序良俗，主播不构成善意

善意取得须同时满足“主观善意、价格合理、产权转移”这三个条件。服务行业本身因成本、需求和竞争的不同，具有明显的层次差异性，但价格并非没有市场衡量标准。评判是否价格明显不合理，需要以一般理性经济人的标准来进行衡量，若明显超出了一般经济人的理性，那就应当认为属于“明显不合理对价”的交易行为，可纳入刑事追缴的范围。本案被告人在短短半年时间里，就在平台账户消费247万余元，打赏239万余元。打赏的金额与提供的直播服务相比，显然超出了一般经济人的理性范畴，应属于不合理对价的交易行为。平台应有义务对用户的打赏金额和频度设置相应的提醒和限制，对发现主播诱导用户打赏时，应采取及时的干预、限制措施。而主播与用户具有较多的互动，有可能知道用户的一些基本情况，当知道或应当知道打赏款来路不正时，仍接受打赏礼物，甚至与用户建立线下联系，引诱用户更高额的打赏，主播主观上不构成善意，客观上也有违公序良俗，不应适用善意取得。

三、追缴的对象及于平台和其他利益分成者

“充值—打赏”的直播打赏消费模式一般涉及用户、主播、直播平台等多方法律关系。用户已充值但未打赏消费的金额，预付款所有权仍应归属于用户，可直接进行追缴。对于已经消费的打赏款，赃款虽已实现了所有权的转移，但主播与平台之间对外是一体的关系，主播行为不构成善意，即便平台构成善意，也不能适用善意取得制度。追缴的对象不仅包括被告人非法占有的财产，还包括已被其处置的财产。对用不符合善意取得应追回的赃款，办案机关应妥善查明相关的打赏记录以及赃款的具体流向，对包括网络主播、直播平台等打赏款的所有分成参与者进行追缴。

编写人：江西省吉安市吉安县人民法院 彭小宁

向案外人追缴涉案财物的认定与适用^①

——高某等诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2022)京02刑初60号刑事判决书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2018年7月至2019年12月，被告人高某等9名被告人伙同他人，以某拍卖公司、某贸易公司等多家公司的名义，给被害人拨打电话，虚构能够帮助被害人将收藏品高价拍卖等事实，邀约被害人前往公司，后以收取委托拍卖合同佣金、拍卖服务费、拍卖保证金等名义，骗取300余名被害人钱款共计1400余万元，其中大部分被害人系老年人。2020年7月，上述9名被告人相继被抓获归案。案发后，高某等5名被告人的亲属代为退赔被害人损失68万元。另查明，2018年6月，被告人高某借用郭某母亲李某的身份证、银行卡等注册成立某拍卖公司，郭某将其母亲身份证、银行卡等材料邮寄给高某。高某使用李某该银行账户作为某拍卖公司的收款账户，用于收取诈骗所得赃款。2019年12月，李某将该账户挂失，将账户内余额27万余元据为己有。

【案件焦点】

1. 在法院审理阶段，庭前通过审查案外人证言发现其涉嫌占有涉案财物的

^①入库案例，参见人民法院案例库2023-04-1-222-005。

线索，如何认定财产权属，确定其是否符合应当追缴的情形。2. 如何适用向案外人追缴涉案财物的程序。

【法院裁判要旨】

北京市第二中级人民法院经审理认为：本案法庭在审理过程中，公诉机关出示了证人李某、郭某的证言，被告人高某的供述及李某银行账户交易明细，证明李某占有涉案赃款27.3082万元，建议法庭责令李某退赔涉案赃款。证人李某、郭某的证言，被告人高某的供述及李某银行账户交易明细，能够证明李某将涉案银行卡挂失后，将卡内钱款27万余元支取占有，上述27万余元系各被告人以某拍卖公司名义诈骗被害人的赃款。证人李某、郭某的证言和被告人高某的供述关于郭某与高某之间是否存在债权债务关系存在矛盾，二证人虽称郭某对高某具有债权，但无法提供借条、银行转账记录等书证，亦无法提供其他证人予以佐证；且李某明知卡内钱款系高某以公司名义实施诈骗所得，无论郭某与高某是否存在债权债务关系，其均不能善意取得、合法占有涉案财物。综上，关于公诉机关所提对案外人李某追缴涉案赃款的建议，法院予以采纳。

被告人高某、王某、张某、慕某、曹某、刘某、张某甲、丁某、张某乙伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。据此，以诈骗罪分别判处被告人高某有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币15万元；判处被告人王某有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币12万元；判处被告人张某有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币11万元；判处被告人慕某有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币8万元；判处被告人曹某有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；判处被告人刘某有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；判处被告人张某甲有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；判处被告人丁某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；判处被告人张某乙有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；责令各被告人依法退赔被害人损失；责令李某退赔人民币273082元，并入退赔某拍卖公司诈骗事实部分被害人项执行；在案扣押的钱款并入退赔项执行；未随案移送的扣押物品由扣

押机关依法处理。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

人民法院审理养老诈骗等案件，应当加大追赃挽损力度，准确甄别、审查、认定涉案财物，对于有证据能够证明案外人并非善意取得涉案财产的，应当依法判决向案外人追缴涉案财产，最大限度挽回受害群众经济损失。本案的争议焦点问题是，法院在审理阶段发现案外人涉嫌占有涉案财物的线索，如何准确认定涉案财物权属并依法启动向案外人追缴程序。

第一，准确认定案外人占有涉案财物的权属，有两项审查要点，即：案外人所占有的财物是否属于违法所得或者依法应当追缴的涉案财物；是否构成阻却刑事追缴的善意取得。本案中，案外人占有诈骗犯罪所得财物，属于涉案财物并无争议。关于案外人对涉案财物是否构成清偿债务型善意取得，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款从主观明知、合理对价、取财方式等方面说明了善意取得的否定性要件。

本案中，案外人李某所占涉案财物不构成善意取得，应予追缴。一方面，在案证据并不能证明李某与被告人存在债权债务关系，李某不存在善意取得的合理对价。李某、郭某虽称郭某对高某具有债权，该笔钱款应认定为高某的还款，但高某否认与案外人存在债务关系，并称曾向案外人索要该27万余元钱款，案外人拒不退还，双方言词关于郭某与高某之间是否存在债权债务关系存在矛盾。李某一方无法提供借条、银行转账记录等书证，也无法提供其他证人予以作证，未达到高度盖然性的证明标准，其主张无法得到支持。另一方面，李某明知卡内钱款属于诈骗所得，不符合善意取得之善意要件。在李某证言中，其知晓高某使用其银行卡从事诈骗活动，也明知这张银行卡内钱款不归其所有，可见李某对卡内27万余元是违法所得具有明知。

第二，启动向案外人追缴涉案赃款程序，应当坚持以审判为中心，确保对涉案财产权属证据的调查在法庭、对涉案财产处置意见的辩论在法庭、对涉案

财产甄别认定的裁判结论形成在法庭。本案中，李某占有涉案财物系审判阶段发现的、未被采取强制措施，不属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百七十九条中“查封、扣押、冻结财物及其孳息”的财物范畴，不能直接适用关于当庭调查的程序，但根据当然解释，对于未被采取强制措施的涉案财物，未经侦查机关、公诉机关初步审查，更应当适用当庭调查程序查明权属，保障当事人、案外人的合法权益。因此，应当由公诉机关就是否向案外人追缴财产提出处置意见，并负有在法庭调查中举证证明处置意见合法、合理的责任。同时，法庭应当听取被告人、辩护人等诉讼参与人的质证、辩护意见，案外人对涉案财物提出权属异议的，应当听取案外人的意见，必要时可以通知案外人出庭。

本案中，审理法院庭审前通过审查案外人在侦查机关所作证言发现其涉嫌非法占有涉案赃款的线索。法院联系案外人李某、证人郭某，以听取案外人的意见、保障案外人参与诉讼的权利，经多次联系未果后将相关线索移送给公诉机关，截至本案开庭审理前，公安机关已对李某涉嫌刑事案件进行立案，李某在逃未到案。因此，审理法院在穷尽全部通知手段但案外人、证人未能到庭的情况下，在庭审中安排了涉案财物处理的调查环节，由公诉机关说明情况、提出处理建议，公诉机关出示了证人李某、郭某的证言，被告人高某的供述及李某银行账户交易明细，证明李某占有涉案赃款27.3082万元，建议法庭责令李某退赔涉案赃款。组织控、辩双方针对案外人证言等证据进行举证、质证；在法庭辩论环节，组织控、辩双方围绕争议焦点进行充分辩论，各被告人及辩护人对公诉机关建议均未提出异议，审理法院最终采纳了公诉机关的处理建议，判决向案外人追缴涉案财物，并在裁判文书中写明责令退赔的方式及退赔数额，对判决所依据的证据、事实及法律进行阐明和说理，最大限度确保向案外人追缴涉案财物的程序公正合法。

编写人：北京市第二中级人民法院 常燕 何朕

网络恶势力“套路贷”行为的认定与刑法规制

—— 顾某某等诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市高级人民法院(2023)沪刑终17号刑事裁定书

2. 案由: 诈骗罪

【基本案情】

2020年5月至2021年7月,被告人顾某某及其妻子被告人王某某通过实际控制的某信息科技公司,开发设计并实际控制爱峰、金戒指等23款非法网贷APP和共债数据系统,交由被告人郑某等人用于对外放贷,并联系资金结算平台。郑某等人分头纠集人员,使用上述网贷APP及顾某某提供的公民个人信息,隐瞒网贷APP自动调取手机通讯录等事实,以低息、无抵押等诱骗他人网上申请小额贷款,收取借款金额30%左右的“砍头息”;还以提高借款额度等诱骗借款人再次借贷,或采用威逼诱骗等手段办理展期,或通过实际控制的关联网贷APP重新借款平账从而不断垒高债务;再用“爆通讯录”、“短信轰炸”、辱骂威胁等软暴力手段进行催收,非法占有被害人钱款。被告人杨某某、袁某某、丁某某、李某某等人受郑某纠集,带领人员负责运营部分网贷APP,实施“套路贷”诈骗犯罪活动。据此,顾某某等人通过网络“套路贷”诈骗全国各地4100余名被害人共计人民币9414.54万余元,未遂人民币4152.54万余元,其中被害人韩某因不堪债务压力身亡。

【案件焦点】

1. 本案的定性；2. 本案是否属于恶势力犯罪集团；3. 本案的犯罪数额。

【法院裁判要旨】

上海市第一中级人民法院经审理认为：(1) 本案系假借民间借贷之名，通过低息、红包等为诱饵骗取被害人签订借贷协议，放贷时直接扣除高额的服务费变相虚增借贷金额，又肆意将还款期限提前为中午12时止，诱骗被害人支付高额展期费进行展期或去被告人实际控制的其他非法网贷APP“平账”，进一步垒高债务。行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相使被害人产生错误认识而自愿建立借贷关系，又使用软硬兼施“软暴力”催讨使被害人“自愿”承担垒高的债务，以获取被害人高额的服务费、展期费等，符合诈骗罪的构成要件，依法应认定为诈骗罪。(2) 对“爆通讯录”“短信轰炸”等非接触网络手段，只要足以对不特定人产生心理威慑、心理强制，可认定为“软暴力”；恶势力主要成员之间虽然人身依附较弱，但首要分子通过掌握信息、技术、资金支付等要素对下实施管理和控制的，亦可认定为恶势力犯罪组织。本案犯罪组织系由多个层级组成，架构完整、成员固定、犯意统一、分工明确，对于有组织的实施电信网络“套路贷”犯罪活动，实施“软暴力”催收，构成“为非作恶，欺压百姓”，造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力犯罪组织。(3) 依据司法解释的规定，本案的犯罪数额应以被告人实际所非法占有的被害人所支付的高额的服务费和展期费为准。同时，对因意志以外原因未得逞的，以已经着手非法占有的财物数额认定为犯罪未遂。本案的既遂、未遂金额均已达到数额特别巨大的法定刑幅度，以既遂酌情从重处罚。据此，依法对被告人顾某某、郑某犯诈骗罪分别判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对被告人杨某某、袁某某、李某某、丁某某、王某某犯诈骗罪，分别判处有期徒刑十五年至十二年不等刑罚，剥夺政治权利四年或三年，并处人民币200万元至60万元不等罚金。

一审宣判后，顾某某、郑某、杨某某、袁某某、丁某某、李某某、王某某提出上诉。

上海市高级人民法院经审理认为：原判认定上诉人顾某某、郑某、杨某某、袁某某、丁某某、李某某、王某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、“套路贷”的认定应把握其本质特征，以“非法占有目的”为核心要旨

“套路贷”是对假借民间借贷之名非法占有被害人财物的一类违法犯罪活动的概括性称谓，传统“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括制造民间借贷假象、制造资金走账流水等虚假给付、故意制造违约或者肆意认定违约等。随着信息网络的高速发展，“套路贷”犯罪也逐渐转移“战场”，向互联网空间延伸，犯罪链条不断拉长，犯罪行为的科技化、隐蔽化、集团化程度日益增强。此时，倘若仍然以传统线下“套路贷”的惯常手法来认定线上“套路贷”，往往会因缺少其中某一环节而得出不构成“套路贷”的结论，不利于犯罪的有效打击。有鉴于此，在认定不断翻新的“套路贷”案件时，必须要结合贷款的具体手段、情节和后果，从整体上把握“套路贷”犯罪的本质，即通过设置层层“套路”非法占有被害人财物，而是否有制造虚假给付事实、是否有故意制造违约等均不是“套路贷”的必备要件。

本案并非传统“套路贷”，不存在传统“套路贷”中常见的以虚假资金走账流水和层层垒高方式虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等主要特征，但高额服务费、期限规则和转台平账等与传统“套路贷”的核心内容并无差异。同时，本案存在以下特征：一是事先精准的“客户引流”，即利用事先精准掌握的借款人信息和共债数据系统等引诱借款人办理借款、展期等业务；二是更加隐密的作案方法和强大的反侦查措施，即明知其行为可能涉嫌“套路贷”犯罪，刻意回避传统“套路贷”常见手法和犯罪特征，研发新型非法网贷模式，如在到期当日才告知12点为还款时间（规避传统

“套路贷”中恶意制造违约、肆意认定违约特征)、口头告知期限规则、隐瞒关联关系、系列反侦查措施等;三是利用电信网络技术(非法网贷APP)实施非法活动。据此,本案系新型“套路贷”。

值得注意的是,“套路贷”犯罪通常假借民间借贷之名,但与民间借贷有本质区别。民间借贷是以自有资金以合法方式赚取合法利息,通常没有砍头息、服务费等,如出现逾期通常以民事诉讼方式主张权利。高利贷则是出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是获取高额利息。而“套路贷”中,出借人以非法占有借款人财产为目的,要求但并不希望借款人及时归还本金和利息,甚至会刻意制造违约达到虚增债务的目的,并使用软硬兼施的催债手段。

本案的被告人不是仅以获取服务费为最终目的,而是以通过提高展期率、复贷率、转台平账率等快速垒高被害人债务从而最大限度获取暴利为最终目的;所实施的利用“料子”、话术和共债数据系统等进行精准营销、展期、复贷和转台平账单等行为系典型的套路贷行为。对于确实存在正常还款和撙贷情形,其中正常还款所占比例甚低(事实上被告人最终目的并非正常借贷),而对于撙贷既是被告人本身刻意防范的情形,又是被告人在实施犯罪活动中已预估的犯罪成本,且并不包括在本案认定既遂数额中,故均不影响案件的整体定性。

二、对新型网络“套路贷”行为定性应注意对犯罪行为进行全链条审查和完整评价

涉电信网络套路贷行为,因信息网络的利用,突破了传统犯罪的地域时空限制,犯罪链条更长也更为隐蔽。其中,部分行为可能符合相关罪名的构成要件,但片面、割裂地评价部分犯罪事实无法充分体现案件的犯罪过程和社会危害性。故,对新型电信网络“套路贷”行为定性应注意对犯罪行为进行全链条审查和完整评价。本案的被告人在事先已通过“料子”和共债系统掌握了被害人个人信息和急于借款的心理,进而有针对性地进行话术营销,诱骗被害人签订借贷协议;关于借款周期、服务费、展期费、还款截止时间、各网代APP之间关联关系等重要事项进行隐瞒或临时告知被害人;被害人是在被诱骗情况下

网签借款协议、办理展期、复贷、转台平账等逐步垒高债务。被告人的行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相使被害人产生错误认识而自愿建立借贷关系，以骗取被害人高额的服务费、展期费等，符合诈骗罪的构成要件。

1. 被告人主观上具有非法占有的故意：一是被告人均明知所运营的均系非法网贷APP、所从事的均系非法网贷活动；二是被告人均明知只有运营多个非法网贷APP、提高展期率、复贷率、转台平账率等才能快速地、最大限度地获取暴利，尤其是明知其中的展期（展期费占诈骗既遂比例高达50%）和转台平账可以快速垒高被害人债务；三是非法网贷APP均设置了强制读取被害人手机通讯录等、限制取消订单、强制下单等非正常功能；四是各项反侦查措施证明被告人对所实施行为的非法性和“套路贷”违法性具有充分认识。

2. 被告人客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为：一是利用“料子”和共债数据系统事先掌握了精准的被害人（借款人）信息（包括急于借款的心理），再有针对性地采用话术诱骗被害人下载、注册非法网贷APP。二是利用非法网贷APP预设的各种非法功能和界面隐瞒真实借款利息、展期费用和期限规则（主要为：真4假5的借款、展期期限、到期当日12点为还款时间）等，诱骗被害人办理借款、展期等。三是隐瞒非法网贷APP之间关联性等事实，利用共债数据系统等进行转台平账等。

3. 割裂评价本案事实无法全面体现犯罪过程和社会危害性。非法经营行为（放贷行为）和寻衅滋事行为（催收行为）均系整体行为的组成部分，均无法完整、充分地体现本案的犯罪过程和社会危害性。本案是被告人在统一的诈骗犯罪联络下，按照各自分工相互配合共同实施的诈骗犯罪，整体主观故意并非非法经营或寻衅滋事故意，整体行为也不仅仅是非法经营或寻衅滋事行为。据此，以非法经营罪、寻衅滋事等罪名定性的意见，是对案件整体事实片面、割裂地评价，依照想象竞合理论，本案应当按重罪即诈骗罪论处，而不能以非法经营罪或寻衅滋事罪论处或者并罚。

关于敲诈勒索罪的定性意见，在催收时实施“软暴力”行为，从实施的时

间和程度上看,是在被害人“自愿”建立借贷关系之后,难以偿还“债务”时,对被害人施加的程度较轻的胁迫行为。一方面,本案的被害人实质上还是基于被骗而“自愿”承担垒高的债务,在催收阶段的软暴力胁迫主要是保证所诈骗钱款的顺利收取,即犯罪的既遂;另一方面,本案系通过电信网络手段实施的软暴力,对被害人人身权的侵犯程度较低,且依据现有证据也难以证明本案所认定的每一名被害人均遭受到“软暴力”索债,故本案也不宜认定构成敲诈勒索罪。

三、本案中的犯罪集团属于新型网络恶势力犯罪组织

依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的相关规定,恶势力,是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织,其中,其他手段应当与传统意义上暴力、威胁的社会危害性相匹配。

(一)“爆通讯录”“短信轰炸”等非接触网络手段情节严重时可认定为“软暴力”,属于其他手段

所谓“软暴力”,是与传统暴力相对的,非通过对被害人肉体施加痛苦而是通过对被害人精神施加影响的违法犯罪手段。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的相关规定,认定“软暴力”的关键在于其行为手段是否已达到公开性、对不特定被害人产生的心理威慑性,严重影响他人的正常工作生活秩序。本案中,被告人在进行所谓催收时,或向被害人及其通讯录人员发送诋告、人格侮辱短信等进行所谓“短信轰炸”“爆通讯录”,或直接进行威胁、侮辱、谩骂等,属于线上即通过信息网络或者通讯工具实施的“软暴力”。虽然不是在线下针对具体人身或财产实施暴力或者以暴力相威胁,但长期的滋扰、威胁给被害人及周边亲朋造成了巨大的精神压力和心理恐惧,扰乱了正常的工作、生活秩序。特别是被害人可能产生的“社会性死亡”后果,导致与身边亲朋无法正

常交往，在人际交往频繁的现代社会甚至会形成比现实暴力更为恶劣的危害后果，应当评价为“软暴力”。

（二）相关案件首要分子通过掌握信息、技术、资金支付等要素对下实施管理和控制的，可以认定为新型网络恶势力犯罪组织

《中华人民共和国刑法》关于犯罪集团规定，有明确首要分子，主要成员固定，其他人员虽有一定流动性的电信网络诈骗犯罪组织，依法可以认定为诈骗犯罪集团。但如首要分子与主要成员之间人身依附性较弱，甚至互不相识，亦不能完全排除恶势力犯罪组织之可能。本案涉案的多名被告人中，上级通过信息技术等手段掌握“客源”、技术、资金结算等经营要素，对下实施管理和控制，结合涉案人员众多、组织严密、层级分明、各环节分工明确的特点，本质上依然是以整体、组织的形态共同实施相关犯罪行为，可以认定有组织犯罪；该组织在江苏省、安徽省两地长期实施非法网贷活动，正如被告人自述“已经站在这个行业金字塔的顶端了”，符合“在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”的恶势力特征；利用预设的非法功能强制获取借款人通讯记录等并加以利用实施所谓的“短信轰炸”“爆通讯录”等“软暴力”，催收逼债，牟取暴利，严重滋扰被害人正常工作生活，显已构成“为非作恶，欺压百姓”，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为新型网络恶势力犯罪组织。

本案是一个具有新型“套路贷”、新型“软暴力”、新型“恶势力组织”等特征的恶势力犯罪集团案件。案件显示出的犯罪链条长、作案手段隐蔽性强、精心设计“套路”等导致司法认定争议大等问题，要求我们不能囿于传统的线下犯罪模式，应随时适应技术革新与滥用，紧盯黑恶势力犯罪在信息网络空间的延伸发展态势，把握犯罪的本质特征，准确定性、妥当量刑。

编写人：上海市第一中级人民法院 周婧

使用诈骗手段将合法债务转化为虚假的投资 不构成对被害人财产利益的实质性损害

——张某某诈骗、伪造国家机关证件案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01刑终389号刑事判决书

2. 案由：诈骗罪、伪造国家机关证件罪

【基本案情】

2021年6月，被害人滑某在看房时结识销售房产的张某某，后滑某向张某某转账10万元用于双方合伙投资开民宿。2021年6月、7月，张某某向滑某提议合伙开临期食品超市，并虚构其已联系好独家代理合同需支付保证金、已得到产品独家代理权、超市前期进货、租赁店铺等理由让滑某转账，滑某陆续转账33.8037万元。其中，2021年7月7日转账的3万元中，滑某称有2万元系借款，7月9日其与张某某聊天时将该2万元计入投资超市的钱款；7月11日张某某女友退还滑某1.6万元。2021年7月8日，张某某虚构其女友的朋友买房向滑某借款10万元。为隐瞒其犯罪行为，拖延报案，张某某向滑某提供盖有“某市自然资源和规划局”印章的伪造房产证一份。张某某于2023年2月17日被公安机关抓获。案发后张某某女友退还被害人滑某10万元。

【案件焦点】

被害人将自己合法的债权转为虚假的投资事项，是否构成实质性财产损失。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人张某某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，应与其所犯诈骗罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：

一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币4万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币43000元；

二、责令被告人张某某退赔人民币46万元，发还滑某；

三、在案扣押假房产证一本，予以没收；手机三部，退还被告人张某某。一审宣判后，张某某提出上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：上诉人张某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪且数额巨大，依法应予惩处。张某某伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，应与其所犯诈骗罪数罪并罚。一审法院根据张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，定性准确，审判程序合法。因二审期间出现新证据且原判认定犯罪数额有误，其中滑某向张某某的转账中有6000元没有书证，滑某也承认不存在该笔钱款，张某某女友在案发时间段曾退还给滑某1.6万元，以及2021年7月9日滑某与张某某协商转为投资超市的2万元借款，上述钱款均应在犯罪数额中扣除。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第三项；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：

一、撤销北京市海淀区人民法院(2023)京0108刑初675号刑事判决;

二、上诉人张某某犯诈骗罪,判处有期徒刑八年三个月,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币4万元;犯伪造国家机关证件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币3000元,决定执行有期徒刑八年十个月,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币43000元;

三、责令上诉人张某某退赔被害人滑某人民币318037元;

四、在案扣押的假房产证一本,予以没收;手机三部,变价后折抵上述退赔款。

【法官后语】

诈骗罪的法益侵害体现为使被害人遭受财产损失,财产损失应当以被害人的财物或财产性权益实际减少为判断标准。在以财产性利益为诈骗对象的场合,处分行为主要表现为将财产性利益输送给对方,即承担某种义务或者放弃某种权利,一般包括债权取得和债务免除两种情形。在债权取得的情形中,行为人使用诈骗手段给被害人增设债务,使被害人面临财产损失的风险,但最终没有发生实际的财产转移,根据结果未发生的原因,可能不认为是犯罪或者构成诈骗未遂。在债务免除的情形中,债权人向行为人给付金钱时是基于合法有效的借贷关系,债务免除不会发生财产的二次交付,只有行为人使用诈骗手段使被害人失去借据、欠条等借款凭证,且该凭证是确认债权债务关系存在的唯一证明,导致债务彻底消灭时财产性利益才会遭受损害。这里要强调的是,债务免除的关键在于导致债务灭失,而非诈骗取得借款凭证。例如,A借款给B并签订了借条,已经超过诉讼时效,B使用诈骗手段取得该借条,后A以银行流水等证据诉至法院要求B返还借款,B认可债务存在,法院据此判决支持A的诉求,此时B虽然实施了诈骗借条的行为,但因没有危害到A的任何利益,不构成犯罪。

债务转化不是刑法意义上的债务免除,被害人并没有放弃自己的钱款,只是将其挪作他用,仍然享有该笔借款产生的其他民事权利。以本案为例,2万元借款转为投资款后,滑某原来基于借贷关系的债权请求权,就变为基于合伙

关系的投资收益请求权，在形式上被害人的财产性利益没有减少或灭失。有观点认为，合法债务转为虚假的、不可能实现的投资，就应当构成实质性财产损失。但问题是，未能按期偿还的借款与不能兑现的投资，在结果上并无二异，即使有证据证明投资是虚假的，但被害人最后遭受的财产损失，究竟是被告人没有还款能力造成，还是想据为己有，除非被告人自认，否则难以作出清晰区分，在此情况下就无法建立财产损失与虚构事实之间的因果关系，也就无法认定被告人构成诈骗罪。与此同时，债务转化并不当然就意味着对被害人不利。例如，A 正常借给 B 一笔钱，并签订了借条，但是已经超过诉讼时效，A 向法院起诉不会得到支持，后 B 以非法占有目的诱使 A 将该笔借款连同其他钱款一并转为新的借款，并签订了借条，此时 A 反而可以依据新的借条主张实现该笔借款。而且，在现代社会，民法应当扩张，刑法应当谦抑，除非有证据证明借款时即具有非法占有目的，债务人仅以欺诈等方式拖延还款的情形不可一概纳入刑事管辖范围。

还需要考虑的是，纳入刑事评价视野的应当具有一定社会危害性的行为。《刑事审判参考》第1342号指导案例^①在区分民事欺诈与刑事诈骗时认为，一般来说，构成诈骗罪的行为，应当是不能通过民事途径进行救济的行为。本案中，如果滑某以投资合作关系向法院主张相关权益或返还投资款，张某某要么认可二人存在投资合作关系，要么承认其对滑某存在欺诈行为。在前一种情况下，滑某的财产权益会得到法律保护。在后一种情况下，根据《中华人民共和国民法典》第一百四十八条的规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。据此，滑某可以通过行使撤销权，恢复其与张某某之前的借贷关系。

编写人：北京市第一中级人民法院 魏小项

^①参见最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办：《刑事审判参考》（总第122集），法律出版社2020年版。

被害人参与度对请托型诈骗定性的影响

——张某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03刑终369号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

被告人张某与被害人赵某早前因工作相识。2019年7月初，赵某的母亲孟某某因涉嫌诈骗罪被河南警方刑事拘留。被告人张某在本市朝阳区等地，向赵某某谎称自己在司法系统有关系，以帮助赵某母亲孟某某脱罪为由，诈骗赵某某人民币300万元。

赵某之母孟某某因犯诈骗罪于2020年11月27日被河南省某市中级人民法院判处有期徒刑，孟某某提出上诉。赵某为转移其母亲名下账户钱款，于2020年12月5日至11日，将孟某某账户中的人民币269万元转至自己账户。2020年12月11日12时44分许，赵某在某银行某支行取现人民币260万元。后赵某与张某共同前往某银行某支行，赵某在外等候，张某一人进入银行办理业务。当日16时0分许，张某账户存入现金人民币260万元。在张某存款期间，赵某在银行外等候，二人通过微信就钱款是否存活期、存款期限等进行频繁沟通。2021年8月，河南省高级人民法院就孟某某等人案针对孟某某维持一审法院的判决。2021年8月至9月，赵某及其家人多次通过拨打电话及发送短信方式联系张某，催促张某还款未果。

2021年12月31日赵某报警称被张某诈骗人民币560万元，2022年1月2日，公安机关对张某诈骗案决定立案。张某同日被抓获。

【案件焦点】

1. 被害人赵某在被告人张某的涉案行为中有较高参与度，是否影响张某诈骗罪的成立；2. 被告人张某诈骗的金额如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：被告人张某所存两笔钱款即人民币560万元均来自被害人赵某。从赵某取款时张某的参与度来看，赵某将取款事宜告知了张某。而从张某存款时赵某的参与度来看，赵某对办卡存钱是知情的。现有证据足以证明张某以虚构事实或隐瞒真相的手段骗取了赵某人民币300万元，但无法证明赵某的260万元系被张某骗取。被害人赵某虽然前后陈述存在部分变化，但其就给张某钱款的缘由系为了帮赵某之母孟某某脱罪的陈述基本一致，现有证据能够证明张某在赵某给其钱款的前后，有给赵某介绍律师、陪同赵某前往河南探视赵某之母等积极参与的行为，上述行为与赵某所述之给钱缘由能够呼应，且上述300万元均系来自赵某本人，与后续的260万元系从其母亲银行卡取出不同。其次，证据证明赵某在其母亲被判刑后有转移其母亲名下财产的主观意图，其除将其母亲的260万元给张某保管外，赵某在之后继续从其母亲账户转入自己账户数笔钱款共计145万元。现有证据无法证明张某对赵某的260万元实施了虚构事实或隐瞒真相从而骗取钱款的行为。据此，以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币11万元。

一审宣判后，被告人张某提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：一审法院对被告人张某构成诈骗罪的定罪及适用法律正确，量刑适当，对在案扣押、冻结款物及对责令继续追缴被告人违法所得的处理亦无不当，审判程序合法，应予维持。故裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

区分民事欺诈与刑事诈骗的关键在于审查行为人是否具有非法占有的主观目的。对行为人虚构自己具有实现请托事项的能力，骗取被害人信任进而收取被害人钱款的请托型诈骗，在判断行为人行为是否具有非法占有的主观目的时，被害人在行为人行为中的参与程度亦是重要考量要素。在无其他充分证据对行为人处分钱物时具有非法占有目的予以印证时，被害人参与度如果超出普通认知的“沟通”，可能构成对诈骗事实认定的阻断。不能仅依据行为人在基于被害人高参与授权处分被害人钱物后，产生占有钱物的事后故意，认定行为人构成诈骗罪。

诈骗类犯罪在当前一审、二审案件中均占比较高，该类案件的被告人多拒不认罪。刑事诈骗与民事欺诈并非对立关系，前者系后者中最为严重的部分，在涉及刑民相互交叉或牵连的法律关系时，需把握好“非法占有目的”这一判断标准。在依据事前、事中和事后的时间点对行为人行为进行阶层梳理仍对得出“非法占有目的”之结论存在障碍时，重点分析被害人在该三个时间段中的参与程度亦会对案件的定性产生重要影响。本案即系一起在审理中因充分考量了被害人参与度，对公诉机关指控部分事实未予认定的典型案例。

一、“非法占有目的”是刑民界分的利剑

刑民交叉的视野下，如何对诈骗犯罪和民事欺诈进行区分是司法实务的难点问题。对于两者，可以从欺骗程度(足以使他人产生认识错误并处分财物的程度)和非法占有目的等方面进行区分。

(一) 欺骗程度方面

行为究竟属于民事欺诈还是诈骗犯罪，界分的关键之一在于欺骗程度的判断。欺骗程度是指行为人采用的欺骗方法，是否达到使他人产生认识错误并处分财物的程度。在刑民交叉的案件中，如果行为人采用的欺骗手段达到了使他人产生认识错误并处分财物的程度，则构成诈骗罪；如果行为人虽然采用欺骗手段，但并没有达到使他人无对价交付财物的程度，则只是民事欺诈，尚不构成诈骗罪。

